

1500633-08.2020.8.26.0269

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... apto a ensejar o incremento do tráfico de entorpecentes, a par de outros delitos associados ao uso indevido da droga. Ademais, deve ser ponderado que o E. Supremo Tribunal Federal, a quem compete o controle de constitucionalidade das normas, em momento algum reconheceu a indigitada inconstitucionalidade, razão pela qual o dispositivo de lei há que ser observado e cumprido" (RE 635660 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1500633-08.2020.8.26.0269 - Controle 2021/000220

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAPHAEL FIDELIS SIQUEIRA CAMPOS

Data da Audiência:

06/10/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes, verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública. Ausente o Acusado Raphael Fidélis Siqueira Campos que se encontra em liberdade e foi devidamente intimado às fls. 162. Foi ouvida a testemunha Bruna Simões de Almeida arrolada pelas partes. O depoimento foi registrado pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(^a). Juiz(a) foi dito que: Decreto a revelia do acusado e não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, O réu foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06, "caput", do Código Penal, pois, no dia 17 de fevereiro de 2020, por volta de 20hs, na Rua Luiz Andreolo, n. 125, Vila Camarão, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para fins de uso pessoal, uma pequena porção de "maconha", capaz de determinar dependência física e psíquica, consoante laudo químico-toxicológico encartado às fls. 13/15 e auto de exibição e apreensão a fls. 09/10. A denúncia foi recebida em 17/02/2021 (fls. 64). O réu foi citado por edital, não compareceu em juízo e não constituiu advogado, motivo pelo qual o processo e o prazo prescricional foram suspensos com fundamento no artigo 366 do CPP (fls. 75). Após, o acusado foi localizado e pessoalmente citado (fls. 95). Resposta escrita à acusação devidamente apresentada (fls. 133/134). Durante a instrução foi ouvida a testemunha arrolada pelas partes. O réu não foi interrogado. É este o breve relatório. Penso que a ação deve ser julgada procedente. A materialidade do delito resta comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 13/15) e

pelas demais provas produzidas durante a instrução processual. A autoria também foi devidamente demonstrada. Vejamos. Em solo policial, o réu disse que havia adquirido uma porção de "maconha" para seu próprio consumo, pagando R\$ 10,00 pela droga. Disse que avistou a viatura policial e dispensou a poção, mas acabou abordado pelos agentes públicos, que recuperaram a droga (fls. 02/03). Em Juízo, o réu optou pela revelia. A prova oral também é suficientemente segura ao incriminá-lo. De fato, diz a denúncia que os policiais militares Toledo e Bruna estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram o denunciado Raphael dispensando algo no chão. Após verificarem o objeto dispensado constataram trata-se de uma pequena porção de "maconha" e a importância de R\$ 10,00 (dez reais). Os fatos foram presenciados pelos adolescentes Maria Eduarda e Kauan. Em seguida, o denunciado foi conduzido até a delegacia de polícia. Pois bem. Agora, a policial Bruna afirmou que patrulhava com o parceiro, quando 03 quatro indivíduos na via. Eles estavam acompanhados de uma adolescente. Todos eram conhecidos dos meios policiais. De pronto, pôde notar que o acusado dispensou algo. Tratava-se da "maconha" apreendida. A menor afirmou disse que estava no local para a aquisição de drogas. Como se vê, a prova é firme ao incriminar o acusado. Registre-se que todas as provas produzidas durante a instrução processual evidenciam que o acusado praticou o crime descrito na denúncia. As palavras da testemunha foram firmes e detalhadas, de modo que merece todo crédito. Convém destacar que não há qualquer indício de que esteja mentindo para incriminar um inocente. Os antecedentes do réu e sua reincidência específica (fls. 100/102 e 103/106) recomendam a fixação de pena de 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade (art. 28, inc. II, parágrafo 4º, da Lei de Tóxicos). Ante o exposto, requer e espera o Ministério Público a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM Juiz, O acusado foi denunciado como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06. A ação penal, no entanto, não merece prosperar, pelas razões que seguem. 1- Do art. 28 da Lei de Drogas. Atipicidade da conduta. Inconstitucionalidade e inconveniência do art. 28 da Lei n. 11343/06. Precedentes. O tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06 viola o direito à intimidade e o princípio da lesividade penal, padecendo de inconstitucionalidade. O inciso X do artigo 5º da Constituição da República assevera que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". Assim, por meio deste dispositivo legal, a Constituição atribuiu ao indivíduo liberdade para escolher seu modo de vida. Não é legítima a norma penal, em um Estado Democrático de Direito, que pretenda tutelar a saúde ou integridade de uma pessoa contra sua própria vontade e interesse, sendo tal pretensão intangível ao poder estatal. Só é admissível a intervenção do Direito Penal quando houver lesão concreta ou real, transcendental, grave ou significativa e intolerável ao bem jurídico tutelado. Logo, sob a ótica do princípio da lesividade, não existe crime sem lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bem como não há crime quando a conduta viola apenas bens jurídicos pessoais, por força da ausência da transcendência da ofensa. Por este motivo, não é admissível a criminalização do porte de drogas para consumo pessoal, pois tal conduta não ultrapassa o âmbito privado do agente. Assim, reside a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas em dois pontos. Primeiro, porque o comportamento previsto no tipo não transcende a esfera pessoal do usuário, violando, assim, sua intimidade (vida íntima) e privacidade (autonomia privada) e ferindo, dessa forma, o princípio da transcendência. Em segundo lugar, a conduta prevista no tipo viola o princípio da lesividade, porque não há lesão ou perigo concreto a bem jurídico. Foi reconhecida a repercussão geral sobre o tema "tipicidade penal do porte de droga para consumo pessoal" no julgamento, pelo STF, do Recurso Extraordinário n. 635.659. O julgamento do recurso ainda não foi concluído, mas o Min. Gilmar Mendes, relator, declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas sem redução de texto, votou pela descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, mas mantendo as sanções previstas no dispositivo legal, conferindo-lhes natureza exclusivamente administrativa. Pelo mundo, as experiências descriminalizadoras são positivas. Os países que adotaram a

descriminalização do consumo de entorpecentes observaram uma redução no índice de consumo e é chegado, portanto, o momento de o Brasil adequar-se ao paradigma contemporâneo para o tratamento do tema. Assim, considerando a evidente inconstitucionalidade do dispositivo, o acusado deve ser absolvido, nos termos do art. 386, III do CPP. 2- Da dosimetria da pena. Na hipótese de eventual desfecho condenatório da ação penal em apreço, requer seja aplicada a pena de advertência, prevista no inciso I do art. 28 da Lei de Drogas, dando-se a pena por cumprida. Por fim, requer seja concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, já que não há razões neste momento para a decretação pela custódia cautelar. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. RAPHAEL FIDELIS SIQUEIRA CAMPOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28, "caput", da Lei n. 11.343/2006, porque, em 17 de fevereiro de 2020, por volta das 20 h, na Rua Luiz Andreolo, n. 125, Vila Camarão, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo, para uso próprio, uma porção de "maconha", substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denúncia foi recebida, fls. 64, e o Réu citado por edital, fls. 69, não compareceu em juízo e não constituiu Defensor, assim o feito foi suspenso, fls. 75. Na sequência o Réu constituiu Defensor, fls. 79, e, citado pessoalmente, fls. 95, respondeu a acusação por intermédio da Defensoria Pública, fls. 133/134. Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e, ao final, o Réu foi interrogado (gravação por videoconferência). Em alegações finais o Dr. Promotor de Justiça pediu a condenação do Réu; por outro lado, a Defesa insistiu na absolvição. É o relatório. I – FUNDAMENTO. A ação penal é procedente. Às fls. 09/10 foi juntado o Auto de Exibição e Apreensão no qual consta: uma porção de maconha, com peso de 4,9 gramas. O Laudo de Exame Definitivo em Substância Entorpecente n. 64.696/2020, fls. 13/15, constatou a presença do princípio ativo TETRAHIROCANABINOL (THC). Bruna Simões de Almeida, policial militar, testemunha, disse que estava em patrulhamento, quando se deparou com o Réu e, ao lado dele, havia dois adolescentes e uma testemunha; o Acusado, ao ver os policiais, dispensou uma porção de "maconha". A adolescente Maria Eduarda disse que iria comprar uma porção de droga do Réu, mas não conseguiu em razão da chegada da equipe policial. Confrontando-se a prova coligida infere-se que o Réu foi visto quando trazia consigo 01 porção de "maconha"; tentou ludibriar os policiais ao jogar a droga ao chão, o que visto por eles, que fizeram a apreensão do entorpecente. Pela quantidade apreendida e ausentes observações de venda, verifica-se a destinação pessoal. Confirmada a suficiência das provas, não merece prosperar a tese da atipicidade da conduta, pois, apesar de ter se operado a despenalização da conduta de porte de drogas para consumo próprio, não ocorreu a sua descriminalização. O artigo 28 da Lei n.º 11.343/06 não prevê em seu preceito secundário qualquer pena privativa de liberdade, mas prevê sanções de outra natureza, logo houve mera despenalização, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em Questão de Ordem: "I. Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da L. 11.343/06 - nova lei de drogas): natureza jurídica de crime. 1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII). 2. Não se pode, na interpretação da L. 11.343/06, partir de um pressuposto despreço do legislador pelo "rigor técnico", que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado 'Dos Crimes e das Penas', só a ele (L. 11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 3. Ao uso da expressão "reincidência", também não se pode emprestar um sentido "popular", especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C. Penal, art. 12). 4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o

art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30). 6. Ocorrência, pois, de 'despenalização', entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C. Penal, art. 107). II. Prescrição: consumação, à vista do art. 30 da L. 11.343/06, pelo decurso de mais de 2 anos dos fatos, sem qualquer causa interruptiva. III. Recurso extraordinário julgado prejudicado." (RE 430105 QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1.ª Turma, DJe. 27.04.2007). "[...] A punição, na hipótese, é de rigor para salvaguardar a sociedade do mal potencial causado pelo porte de droga, apto a ensejar o incremento do tráfico de entorpecentes, a par de outros delitos associados ao uso indevido da droga. Ademais, deve ser ponderado que o E. Supremo Tribunal Federal, a quem compete o controle de constitucionalidade das normas, em momento algum reconheceu a indigitada inconstitucionalidade, razão pela qual o dispositivo de lei há que ser observado e cumprido" (RE 635660 SP, rel. Min. Carlos Ayres Britto, 22.3.2011). Destarte, é impositiva a condenação por incidir o Réu no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06. II - DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. Atento às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e aos critérios contidos no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 aplico ao Réu a pena de advertência. III - DECIDO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e o faço para condenar RAPHAEL FIDELIS SIQUEIRA CAMPOS, qualificado nos autos, a pena de ADVERTÊNCIA, dando-o como incurso no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06. Dá-se a pena por cumprida. Sem condenação nas custas. O Réu respondeu em liberdade a este processo e, tendo em vista a pena aplicada, poderá recorrer nessa condição. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 06 de outubro de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA